

1002948-11.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: José Luiz de Jesus Vieira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... o requerente teve consciência do furto. Em contato com o Banco e instituições administradoras dos cartões de crédito o Requerente pediu para que fosse devolvido o valor subtraído ou creditado nas próximas faturas e todos julgaram improcedente" e não ressarciram os valores subtraídos nas contas do requerente. Assim, não restou outra saída a não ser buscar socorro no Poder ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro nº 433 - 5º andar, 5º andar - Sala 501, Penha de França - CEP 03634-010, Fone: 2093-6612r6004, São Paulo-SP - E-mail: penha1cv@tjsp.jus.br

C O N C L U S ã O

Em 06 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França, Comarca de São Paulo. Thais da Silva Ribeiro, Escrevente Técnico Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1002948-11.2022.8.26.0006 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Alvaro dos Santos Saraiva

Requerido:

Nubank Pagamentos S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira

Vistos.

ÁLVARO DOS SANTOS SARAIVA ajuizou em 17/03/2022 "ação de ressarcimento de danos materiais e morais" em face de NU PAGAMENTOS S.A., alegando, em síntese, que "(...) No dia 29 de agosto de 2021 (domingo), por volta das 16:00, o requerente recebeu em sua casa um homem chamado Alex interessado em adquirir alguns produtos seus que estavam à venda. O requerente se recorda de ter tomado uma cerveja na companhia do Alex, e adormeceu, acordou por volta das 3:00hs da madrugada do dia 30 e percebeu que havia sido dopado e furtado. Além do notebook, celular e demais pertences descritos no boletim de ocorrência que segue anexo, foi furtado também seus cartões de crédito e débito. O requerente possuía dados pessoais salvos em seu celular inclusive algumas senhas, acesso ao e-mail, o que permitiu que o delinquente acessasse e alterasse senhas sem o consentimento do requerente. Na segunda-feira, o requerente acessou sua conta da Caixa Econômica Federal e notou que haviam subtraído R\$ 10.000,00 da Conta. Havia feito compras no cartão de débito da Nubank no valor de R\$800,00, e no cartão de crédito Magazine Luiza fizeram compras no valor de R\$ 5.623,37. O requerente entrou em contato com o Banco e as instituições administradora do cartão de crédito solicitou os bloqueios e abriu os protocolos de

Reclamação".

Aduz que "(...) não é habitual o requerente efetuar compras de alto valor ou muitas compras seguidas com seu cartão de crédito, ou solicitar alteração de limite do PIX em um domingo, por volta de 22:00 horas. Frise-se que o cartão foi bloqueado assim que o requerente teve consciência do furto. Em contato com o Banco e instituições administradoras dos cartões de crédito o Requerente pediu para que fosse devolvido o valor subtraído ou creditado nas próximas faturas e todos julgaram improcedente" e não ressarciram os valores subtraídos nas contas do requerente. Assim, não restou outra saída a não ser buscar socorro no Poder Judiciário".

Requer "a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R\$798,99; a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R\$ 10.000,00".

Juntou documentos (fls.12/48).

Deferido ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita (fls.49/50).

O requerido apresentou contestação (fls.55/68), alegando, preliminarmente a ilegitimidade passiva – culpa exclusiva da vítima e terceiros (...). Aduz que "(...) todas as compras validadas com o CHIP são criptografadas e, esta criptografada muda a cada transação. É uma tecnologia mundialmente conhecida e segura o que impossibilita a caracterização de uma fraude, isso porque, a tecnologia por CHIP não permite a clonagem que era relatada em tecnologias anteriores, como da tarja magnética, que era facilmente duplicável, pois sua validação exigia apenas a situação a digitação do código de segurança exposto na parte de trás do cartão (...) o próprio Autor alegou em sua petição inicial que sua senha estava anotada (...) inexistia nexo de causalidade entre a conduta do Réu e os supostos danos suportados pelo Autor (...)".

Juntou documentos (fls.69/89).

Réplica (fls.93/95).

Instados a especificarem provas justificando a pertinência as partes disseram que não tem mais provas a produzir (fls.99/100).

É o relatório.

Decido.

Julgo o processo no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil/2015.

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente descrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório." (STJ, 4ª Turma, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 21.08.90, DJU 17.09.90, p. 9.514).

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida porque o autor pretende a responsabilização do banco pelas movimentações financeiras fraudadas em sua conta bancária administrada pelo banco, o que evidencia a legitimidade passiva. Se procedente, ou não, é questão de mérito.

O autor relata na petição inicial que "(...) No dia 29 de agosto de 2021 (domingo), por volta das 16:00, o requerente recebeu em sua casa um homem chamado Alex interessado em adquirir alguns produtos seus que estavam à venda. O requerente se recorda de ter tomado uma cerveja na companhia do Alex, e adormeceu, acordou por volta das 3:00hs da madrugada do dia 30 e percebeu que havia sido dopado e furtado (...) haviam feito compras no cartão de débito da Nubank no valor de R\$800,00 (...)".

Também relatou o autor à fl. 02 que "(...) O requerente possuía dados pessoais salvos em seu celular inclusive algumas senhas, acesso ao e-mail, o que permitiu que o delinquente acessasse e alterasse senhas sem o consentimento do requerente

(...)"

Preconiza a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

É de conhecimento comum que a relação entre o banco e cliente sempre foi contratada formalmente, assim como, em regra, os contratos adicionais.

No entanto, o rigor das contratações que deixavam inequívoca a convergência de vontades, com a presença dos contratantes e aposição de suas respectivas assinaturas, foi gradativamente sendo abrandado. E isso não o foi por benevolência dos bancos, mas sim porque muito lhes diminuiu os custos com o consequente aumento dos lucros.

E esse abrandamento da comprovação da convergência de vontades traz inerente risco, já que inevitavelmente facilita a perpetração de fraudes das mais variadas.

A questão é quem deve suportar esse risco.

Ontologicamente não há diferença entre um consumidor que seja ludibriado e tenha a senha e cartão bancário obtida por terceiro, como no caso da parte autora, e um consumidor que teve o cartão de crédito furtado/roubado junto com o papel em que anotou a senha do mesmo.

As recomendações unilaterais de que o consumidor "deve" memorizar a senha e não guardar o número junto com o cartão, bem como se atentar com telefonemas que podem ser feitos por fraudadores, embora seja razoável no sentido de se minimizar os riscos, isso esbarra nas limitações pessoais de não raras pessoas, principalmente idosas.

Se isso pudesse ensejar o conveniente rigor que os bancos vociferam para tentar se escusarem do risco inerente aos seus negócios, seria necessária uma prova prévia de aptidão para não ser ludibriado por fraudadores ou para memorizar as senhas de letras e números, tanto mais com o passar dos anos em razão do avanço da senilidade, que exigiria periodicidade de tal avaliação.

Portanto, nenhuma consequência em desfavor do consumidor pode ter o fato de ter sido ludibriado por terceiros fraudadores que obtiveram seu cartão e respectiva senha.

Disso decorre que:

1) O consumidor não pode ser penalizado pela fraude de movimentações financeiras feitas por terceiros fraudadores entre o momento da fraude a inserção da comunicação do crime no sistema do banco, dada a fragilidade do sistema estabelecido pelo próprio banco no abrandamento da verificação da lisura da convergência de vontades nas relações bancárias;

2) O consumidor não é obrigado a ter argúcia capaz de evitar ser ludibriado por hábeis fraudadores, em especial pessoas idosas, razão pela qual não pode ser penalizado por ter sido vítima da fraude; e

3) Não tendo sido comprovada má-fé do consumidor, o banco deve suportar as consequências do risco do seu negócio, agravado pela fragilidade do sistema estabelecido pelo próprio banco no abrandamento da verificação da lisura da convergência de vontades nas relações bancárias quando da realização das movimentações financeiras.

Por consequência, o banco réu deverá estornar todas as movimentações financeiras

indevidas, feitas por terceiros, bem como todos os encargos e/ou tarifas oriundos de tais movimentações objetos do litígio.

No que se refere à pretensão de indenização por dano moral, a despeito das consequências danosas para a parte autora, que teve parte de sua conta bancária violada e valores suprimidos, não se trata unicamente de "fortuito interno" (Súmula 479 do STJ), mas também de agravamento do risco do negócio pela possibilidade de terceiro utilizar cartão e senha (furtados/roubados ou obtidos mediante logro) da vítima para acessar a conta da mesma, e creio que em tais casos a reparação deve se circunscrever ao ressarcimento dos danos materiais relativos às movimentações financeiras indevidas.

Desta feita, a procedência parcial da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a a "ação de ressarcimento de danos materiais e morais" ajuizada por ÁLVARO DOS SANTOS SARAIVA em face de NU PAGAMENTOS S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO A NULIDADE de todas movimentações financeiras objeto do litígio na conta corrente (R\$ 99,99 + R\$ 199,00 + R\$ 500,00 = R\$ 798,99), e CONDENO o banco requerido a ESTORNAR todas as movimentações financeiras e todo e qualquer encargo/tarifas em relação às mesmas, e deverá o banco RESTITUIR ao autor todos os valores, devidamente atualizados pela Tabela do Tribunal de Justiça, desde a data de cada desconto e, a partir da citação, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, que remete ao artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

No mais, verifico que só o banco deverá responder pelo ônus da sucumbência, na medida em que a autora teve razão jurídica para o ajuizamento da ação e teve o pedido principal acolhido, pelo que não se revela razoável que o não acolhimento de pedido acessório tenha outra consequência senão o mero não acolhimento, o que deve ser considerado como sucumbência mínima, razão pela qual condeno o banco recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de R\$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.